

1501590-47.2021.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 31/10/2022

... da audiência, em razão de acusação de tráfico de drogas. Foi acusado por furto, no Maranhão, mas não foi condenado. Relatou não se recordar bem dos guardas municipais. Declarou que o local estava em reforma e quando passou por lá avistou algumas peças de ar-condicionado em uma caçamba de lixo que estava dentro do imóvel. Disse que é reciclador e o muro do local é bem baixo, de modo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTOS
Foro de Santos
6ª Vara Criminal
Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501590-47.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501590-47.2021.8.26.0536 - Controle n.º 303/21
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FABIO CARDOSO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

FABIO CARDOSO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 1º, e parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 3 de maio de 2021, por volta de 1h30min, ou seja, durante o repouso noturno, na Rua Silva Jardim n.º 94, bairro Macuco, neste município e comarca, mediante escalada, subtraiu, para si, dois condensadores de aparelhos de ar-condicionado split, marca Elgin, pertencentes à Prefeitura Municipal de Santos, avaliados em R\$ 1.000,00, cada.

Diz a denúncia que o réu desejava furtar os condensadores dos aparelhos de ar-condicionado, instalados no imóvel do SECRAIDS - Centro de Referência em AIDS de Santos. Assim, dirigiu-se ao local algumas vezes, realizando, aos poucos, a desinstalação dos equipamentos, aos quais teve acesso escalando o imóvel. De madrugada retornou ao imóvel e finalmente retirou os condensadores do local, subtraindo-os e saindo dali na posse dos aparelhos.

A ação foi observada pelo sistema de monitoramento CCO, que acionou a Guarda Municipal. Guardas em patrulhamento dirigiram-se ao local e, munidos das características físicas do furtador, encontraram o acusado nas proximidades. Assim que viu a viatura, o réu tentou fugir e abandonar o carrinho no qual carregava a

res furtiva. Contudo, o acusado foi perseguido e detido pelos guardas municipais, e os condensadores foram recuperados (pp. 96/97).

Recebida a denúncia (pp. 98/99), foi o réu citado pessoalmente (p. 110). A Defesa ofereceu a resposta de p. 118, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 119/120).

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas, procedendo-se ao interrogatório (pp. 174/175).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. Ademais, sustentou a comprovação da qualificadora da escalada, bem como a causa especial de aumento de pena relativa ao repouso noturno. Na dosimetria da pena, pretendeu a consideração dos maus antecedentes e, na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, sustentou a aplicação do regime aberto. Por fim, entendeu impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis (pp. 255/258).

A Defesa, por sua vez, em seu memorial, requereu a absolvição, alegando a insuficiência probatória e a atipicidade da conduta por erro de tipo.

Subsidiariamente, pretendeu a exclusão da qualificadora da escalada, por entender que há dúvida acerca de sua ocorrência. Pleiteou, ainda, a aplicação da pena-base no mínimo legal, além do não reconhecimento dos maus antecedentes, declarando-se a primariedade do réu. Por fim, postulou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, em último caso, a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena (pp. 262/269).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente em parte.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (p. 7), pelo auto de avaliação (p. 67), pelo laudo pericial do local (pp. 142/148) e pelo laudo de degravação de imagens (pp. 154/171).

Perante a autoridade policial, e ciente da acusação que lhe era dirigida, o acusado manteve-se calado, deixando de esclarecer as razões e circunstâncias que ensejaram sua prisão (pp. 10/11).

Em juízo, ao ser interrogado, disse que estava preso, na ocasião da audiência, em razão de acusação de tráfico de drogas. Foi acusado por furto, no Maranhão, mas não foi condenado. Relatou não se recordar bem dos guardas municipais. Declarou que o local estava em reforma e quando passou por lá avistou algumas peças de ar-condicionado em uma caçamba de lixo que estava dentro do imóvel. Disse que é reciclador e o muro do local é bem baixo, de modo que o pulou para pegar os objetos. Disse que não arrancou nada, não tirou nada da parede, pois apenas pegou “coisas velhas, coisas de reciclagem”, que estavam fora de uso. Pretendia vender os bens no ferro-velho. Disse que foi encontrado longe do local, trazendo “as duas sucatas de ar-condicionado” que havia pegado no local em um carrinho de supermercado. Tem 37 anos de idade. Não tem parentes em Santos, veio do Maranhão em 2018 e trabalhava como pintor. No entanto, como teve dificuldades de arrumar trabalho durante a pandemia e acabou se envolvendo com drogas, ficou em situação de rua. Tem uma filha de 6 anos de idade, que mora no Maranhão com a avó paterna. Estudou até a 3ª série, pois começou a trabalhar cedo, por morar em zona rural. Faz uso de crack há um ano e seis meses (gravação audiovisual – pp. 174/175).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Diego Soares Souza, guarda municipal, narrou que recebeu um chamado do CCO, sua Central, durante o período noturno, que estava monitorando um furto em andamento no SECRAIDS. Foram até o local, avistaram o acusado com um carrinho de supermercado, dentro do qual trazia aparelhos de ar-condicionado. Ao avistar a viatura da Guarda Municipal, o réu fugiu. Disse que as câmeras de monitoramento avistaram o réu pulando para o interior do local, mas não teve acesso às imagens, pois apenas foi informado pela Central. Afirmou que, após flagrar o furto, o sistema de monitoramento continuou acompanhando a movimentação do acusado e passou a eles a sua localização exata. Relatou que a Central os informou que o réu estava levando a

res furtiva dentro de um carrinho de supermercado. Não se recorda se o acusado apresentou alguma justificativa para estar com aqueles bens. Apenas se lembra do réu ter afirmado que "ia sair da Delegacia e ia voltar ao local para retirar mais objetos". Não sabe dizer se os bens subtraídos conseguiram ser reinstalados no local. Não conhecia o acusado antes da ocorrência (gravação audiovisual – pp. 174/175).

Rodrigo Bassi, guarda municipal, disse que receberam um chamado pela rede de rádio sobre uma invasão no local dos fatos e que um indivíduo estaria retirando os condensadores dos aparelhos de ar-condicionado da unidade do SECRAIDS. Foram ao local e o sistema de monitoramento acompanhava a movimentação do acusado e a direção para onde ele seguiu. Assim conseguiram localizá-lo a mais ou menos cem metros da unidade. Ele estava com os dois condensadores dentro de um carrinho de supermercado. A Central informou que o furtador era um indivíduo negro, de estatura média, vestindo roupas escuras, características que correspondiam ao acusado, bem como a direção que ele tomou ao sair do local. Solicitaram ao réu que parasse, mas ele tentou fugir, sendo perseguido e capturado em seguida. Afirmou que o acusado ingressou no local pulando o muro, que tem altura mediana. Foi ao local do furto e constatou que os aparelhos estavam instalados na janela do primeiro andar, estimando que foi necessária uma pequena escalada para alcançá-los. Não sabe dizer se foi possível reutilizar os aparelhos subtraídos. Nunca havia visto o réu anteriormente (gravação audiovisual – pp. 174/175).

Vê-se, assim, que não se poderiam entender insuficientes as provas amealhadas, que se revelam coerentes, uníssonas e indicam a condenação.

Sob o crivo do contraditório, os guardas municipais foram firmes, seguros e coerentes em seus relatos, não se evidenciando contradição capaz de retirar valor do contexto probatório.

Os guardas municipais narraram que estavam em patrulhamento e receberam informação via rádio sobre um furto que estava em andamento no SECRAIDS, pois o fato foi flagrado pelas câmeras de monitoramento da Prefeitura.

Narraram que a Central passou a descrição do indivíduo e a informação de que ele levava a res furtiva em um carrinho de supermercado. Ao chegarem ao local indicado pelo monitoramento, depararam-se com o acusado, cujas características correspondiam àquelas passadas via rádio e deram a ele ordem de parada.

O acusado tentou fugir, mas foi detido pelos guardas, que assim apreenderam os condensadores de ar-condicionado retirados do estabelecimento público municipal. Registre-se, ainda, que consoante entendimento predominante, a apreensão da res furtiva em poder do agente e logo após o fato gera presunção da responsabilidade dele na subtração, ocorrendo, assim, inversão do ônus da prova, competindo ao acusado trazer elementos capazes de comprovar que não foi o autor do delito.

Sobre o ônus probatório, colhe-se da lição de Marcos Vinicius Boschi e outros que "conforme iterativa jurisprudência, a apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida. Vale dizer, o ordinário presume-se, o extraordinário é que deve ser provado. A apreensão da res furtiva em poder de alguém, mormente logo após o delito, conforme a experiência ordinária, diz por si mesmo, revelando-se altamente incriminadora. A situação, diz a jurisprudência, assemelha-se a do álibi invocado e não demonstrado, fazendo com que o réu seja havido como confesso, ou, pelo menos, corra o risco de sê-lo, dès que os demais dados probatórios transformem em certeza a presunção gerada pela justificativa dúbia ou inverossímil." (Código de Processo Penal comentado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 169-170).

E, como já se decidiu:

"... Roubo e Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem..." (TJSP; Apelação Criminal 1501570-42.2019.8.26.0628; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021).

De outro lado, sabe-se que o réu não está obrigado a dizer a verdade: ao contrário, bem pode pretender alterar a verdade dos fatos, procurando afastar sua responsabilidade penal, justamente para não se prejudicar.

Nestes termos, inaceitável a versão que o réu ofertou, pois quis fazer crer que o local estava em obras e, ao passar por lá, avistou os bens subtraídos descartados em uma caçamba de lixo, tendo apenas pegado pedaços de sucata de um aparelho de ar-condicionado, supostamente fora de uso, para vendê-la para reciclagem.

Evidente que não há como admitir a fantasiosa versão, uma vez que toda a prova aponta em sentido contrário.

As imagens dos laudos periciais (pp. 142/148 e pp. 154/171) referentes ao exato dia dos fatos oferecem uma ampla visão do local e permitem constatar que não existe qualquer caçamba de lixo no interior do imóvel invadido pelo réu para realizar a subtração.

Não bastasse, a resposta ao ofício encaminhado à Prefeitura de Santos a pedido da Defesa (p. 249) é contundente ao apontar que não havia obra alguma no local.

Não fosse isso, não é razoável acreditar que bens avaliados em cerca de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada (p. 67) fossem simplesmente descartados ou deixados à própria sorte pela administração pública.

Despropositada, por absurda, essa situação.

Impossível, pois, creditar credibilidade a versão tão dissociada de todo o restante do contexto probatório.

Incabível, também, aceitar que o acusado teria entendido tratar-se de bem abandonado e não pertencente a ninguém, uma vez que as provas trazidas ao juízo apontam que ele efetivamente retirou os bens de seu lugar de instalação.

Assim, patente que não se tem fundamento que autorize a absolvição, pois é certo que a prova aqui colhida bem indica que o réu subtraiu os dois condensadores de ar-condicionado descritos na denúncia.

Outrossim, inequivocamente comprovado que se tratou de crime consumado, pois o acusado teve a posse mansa e pacífica da res, ainda que por curto espaço de tempo. Diga-se, ainda, que a qualificadora relativa à escalada é situação perfeitamente configurada.

Note-se que o laudo de exame do local (pp. 142/148) apontou que “O acesso ao interior do imóvel teria se dado, muito provavelmente, mediante ESCALADA em algum ponto do muro frontal, de aproximadamente 2,00m (dois metros) de altura (Foto 03)”, e, ainda, “Foram constatados vestígios de ordem material e aspecto recente relacionáveis com a escalada de aproximadamente 6,0m (seis metros) de altura para a retirada de duas unidades condensadoras de ar condicionado (Fotos 04 'A' e 05) e a escalada de aproximadamente 3,0m (três metros) de altura para a tentativa de retirada de outra unidade (Fotos 04 'B' e 05)”.

Certo, pois, que o réu se valeu de especial destreza e meio não comum para adentrar o imóvel, bem como para alcançar o ponto onde estavam instalados os aparelhos de ar-condicionado, localizados a considerável altura, sendo forçoso reconhecer que demonstrada se tem a qualificadora prevista no inciso II, do parágrafo 4º, do artigo 155, do Código Penal.

Melhor sorte socorre o réu no tocante à causa de aumento de pena decorrente do repouso noturno.

Em recente julgado, proferido em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal é aplicável tão somente ao caput: “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).” (REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022 (Tema 1087)).

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Prevalecia, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o

repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. Essa orientação, todavia, sofreu overruling. 2. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção do STJ fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 3. Ordem de habeas corpus concedida, para afastar o aumento relativo à majorante prevista no art. 155, § 1.º, do Código Penal". (STJ. HC n. 747.967/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022)

Assim, parece que o afastamento da causa especial de aumento de pena é desfecho adequado à situação aqui apurada, uma vez que os fatos narrados na denúncia imputam ao réu a prática do furto qualificado por escalada.

Com efeito, ao que narra a denúncia, o crime ocorreu por volta de 1h30min, ou seja, durante a madrugada, mas como exposto, e segundo o entendimento da Corte Superior, o parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal não mais incide na forma qualificada do crime de furto.

Desta forma, é caso de afastar a incidência da causa de aumento de pena decorrente do repouso noturno.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório. Procede, em parte, a ação penal.

Passo a individualização da pena.

Destaque-se que, não obstante afastada a causa de aumento de pena do repouso noturno, por não incidir no furto qualificado, a situação de fato não pode ser desconsiderada pelo juízo.

Não há dúvida de que o furto cometido durante a noite – período em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da diminuição da vigilância exercida sobre a res – é circunstância determinante no modus operandi dos criminosos.

Assim sendo, essa especificidade será considerada nas circunstâncias judiciais.

O acusado é tecnicamente primário (certidão de pp. 218/219).

Todavia, ostenta condenação definitiva antiga pelo crime de roubo (autos n.º 0048260-22.2004.8.26.0050 – certidão p. 218), a qual, ainda que não sirva para configurar a agravante da reincidência, macula sua vida pregressa e deixa claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...". (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Na hipótese sub judice, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias desfavoráveis do crime, pois o furto foi praticado durante o repouso noturno, aumento a pena-base em 1/3 (um terço), fixando-a em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstâncias que a modifiquem.

Ante o quantum de pena aplicada, o réu faz jus à substituição da pena privativa de

liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que, no caso sub judice, tal medida parece ser socialmente recomendável, e a substituição de uma delas por pena de multa não se mostra adequada à reprovação da conduta criminosa aqui apurada. É necessário gizar que destaque negativo quanto aos maus antecedentes ou às circunstâncias do crime, por si só, não obstat a substituição, pois a análise conjunta de todas as outras circunstâncias do inciso II do artigo referido a indicam como suficiente à repressão e prevenção do crime.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços e prestação pecuniária, na forma do previsto nos artigos 45 e 46, do Código Penal. Fica o réu condenado ao cumprimento de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de prestação de serviços à entidade assistencial, hospital, escola, orfanato ou outro estabelecimento congênere, inseridos em programas comunitários ou estatais, entidade esta que será indicada pelo Juízo da Execução.

Fica condenado, também, ao pagamento de prestação pecuniária estipulada em 1 (um) salário mínimo, a ser pago em dinheiro e em favor de entidade pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução, na forma do previsto no parágrafo 1º do artigo 45 e 46 do Código Penal.

Por ser primário, em caso de conversão de qualquer das penas restritivas de direitos ora impostas, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Não havendo informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar FABIO CARDOSO SILVA, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de prestação de serviços à entidade assistencial, hospitalar, escola, orfanato ou outro estabelecimento congênere, inserido em programas comunitários ou estatais, entidade esta que será indicada pelo Juízo da Execução; e prestação pecuniária, fixada em 1 (um) salário mínimo devido a entidade pública ou privada de destinação social, que também será indicada pelo Juízo da Execução, penas essas que, em caso de conversão, deverão ser cumpridas inicialmente em regime aberto, bem como 13 (treze) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 31 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA